

1501857-23.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... de trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501857-23.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269697/2021 - Delegacia de Polícia de Araçariguama, 2269697 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA, 1774/21/514 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA VITORIA FRANHANI DE JESUS e outro

Aos 12 de maio de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, a ré BRUNA VITORIA FRANHANI DE JESUS, acompanhada de seu defensor Dr. Edson Ferrari Ollof Júnior OAB 394295/SP e BENEDITO DIRCEU DE SOUZA, acompanhado de seu defensor Dr. Bruno Henrique da Silva Custodio OAB 407525/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; e as testemunhas EDUARDO DE FIGUEIREDO KLEIN, MATHEUS FEIJO DANTAS VIEIRA, TATIANA ATANAZIO GERMANO e BENEDITA DE OLIVEIRA RUIVO. Ausentes as testemunhas de defesa HELENA, CARLOS CAMELAS e PAULO DA SILVA CEZAR (não qualificados). Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos das testemunhas Matheus, Eduardo e Tatiane realizados os interrogatórios dos réus Benedito e Bruna. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva das testemunhas Benedita, Helena, Carlos e Paulo. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando

aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: VISTOS. BRUNA VITORIA FRANHANI DE JESUS e BENEDITO DIRCEU DE SOUZA qualificados nos autos foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, associaram-se para a prática do tráfico de entorpecentes, e traziam consigo e transportavam, e mantinham em depósito, para para fins de trafico 04 frascos de lança perfume, 01 porção de maconha, 15 porções de cocaína sendo certo que agiam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também que BENEDITO DIRCEU DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 12 da lei 10826/03, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia possuía no interior da residência 12 cartuchos calibre 45, marca CBC de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/171) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/08), boletim de ocorrência (fls.09/12), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), auto de constatação preliminar (fls.15/16), depósito judicial (fls.150), laudo pericial de munições (fls.157/159), laudo caderno de contabilidade (fls.163/170), laudo celulares (fls.209/218), laudo químico toxicológico (fls.219/223). A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls.179), os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.182/197, 205/208), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas de interesse das partes e com colheita dos interrogatórios. Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação de Bruna pelo trafico não se opondo ao redutor e Benedito pela posse das munições. A Defesa de Bruna insistiu na improcedência com tese secundária de aplicação do redutor no patamar máximo e regime aberto. A Defesa de Benedito em preliminar sustentou a nulidade da prova já que não existiu autorização para ingresso a residência, e no mérito insistiu na improcedência da Ação. É o relatório. DECIDO. Quanto a preliminar arguida durante a instrução quanto ao rito do artigo 212 do CPP, afasta-se a pretensão da Defesa. Saliento que somente durante a inquirição da segunda testemunha, o patrono se manifestou, e não no início da audiência, o que já por si só indica a preclusão da manifestação. Ademais, a princípio os dispositivos do Código de Processo Penal devem ser interpretados dentro de um sistema, e não de forma isolada, como sustentando pela Defesa. A legislação traz que a prova tem como destinatário final o magistrado, sendo que a busca é pela verdade real, de modo, que a modificação do artigo, não trouxe vedação ou proibição ao juiz de indagar testemunhas, e colher o interrogatório. Tanto que o próprio artigo permite as perguntas por parte do magistrado, e nem poderia ser diferente diante do sistema legal vigente, não existindo prejuízos se as perguntas são iniciais ou finais. Ademais, a manifestação da Defesa não apontou durante a instrução qual seria o prejuízo do réu com as perguntas formuladas pelo magistrado. Como é de conhecimento comum, somente é possível reconhecer uma nulidade desde que comprovado o prejuízo, o qual não foi demonstrado pelo acusado, nos termos do artigo 563 e 566 do Código de Processo Penal, ônus que lhe competia e não se desincumbiu. A regra das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (CPP, art. 563). Esse postulado básico pás de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Nesse sentido: "Processual penal. Nulidade sem prejuízo. Inexistência. (...) Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, informativo do Título 'Das Nulidades', constante da lei processual penal" (CPP, art. 5 RSTJ 17/383)." "Nulidade processual. Prejuízo para a defesa. Arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal. Sem a prova da ocorrência de prejuízo para a acusação ou para a defesa, não se anula nenhum ato processual "(RSTJ 17/172)." Ademais e segundo o magistério de Ada Pellegrini Grinover, "A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa

forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação" (in "As Nulidades no Processo Penal", 7ª edição, 2001, revista e atualizada, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, pág. 29). "Nulidades processuais: ausência de prejuízo: 'pas de nullité sans grief. E da jurisprudência do Supremo Tribunal que não se adstringe ao das nulidades relativas o domínio do princípio fundamental da disciplina das nulidades processuais - o velho pas de nullité sans grief-, corolário da natureza instrumental do processo, donde - sempre que possível - ser exigida a prova do prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta" (HHCC 81.510, Pertence, 1ª T., DJ 12.4.02; HC 74.671, Velloso, 2ª T., DJ 11.4.97)." Além de não apresentar ou comprovar qual o prejuízo do acusado, tem-se que nada há nos autos a demonstrar que em algum momento o réu foi prejudicado pela forma de indagação. Também foi garantido as partes as perguntas diretas as testemunhas e réus restando preservado o direito garantido nos termos da nova redação do artigo 212 do Código de Processo Penal. O magistrado ora sentenciante não fez qualquer pergunta com cunho acusatório, pelo contrário, todas foram em forma de esclarecimento e análise da conduta de cada acusado. Alias, indagações que ocorreriam já que necessárias para a busca da verdade real, ora, objetivo do processo penal. Realmente nada trouxe a defesa a demonstrar que o réu foi prejudicado, ou seja, não comprovou o que dispõe a teoria das nulidades. Alias a doutrina vem se solidificando a afastar irregularidade ou nulidade na colheita da prova oral com indagações do magistrado, ora destinatário da prova. Para NUCCI, a nova redação do art. 212 do CPP "não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer, quem começa a ouvir a testemunha é o Juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido. A nova redação dada ao art. 212 manteve o básico" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 8ª ed. rev., atual. e ampliada. São Paulo: RT, 2008, p. 481.). Do mesmo entendimento comungam Luis Flávio Gomes, Rogério Santes Cunha e Ronaldo Batista Pinto (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da lei de trânsito. São Paulo: RT, 2008, p.302). A jurisprudência do STF também vem se manifestando nesse sentido, exigindo prova do prejuízo para análise de eventual nulidade, que seria no máximo relativa, ate porque, não se encontra no rol taxativo do Código de Processo Penal. "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU QUE NÃO DECLINOUS OS DADOS NECESSÁRIOS À INTIMAÇÃO DO DEFENSOR SUPOSTAMENTE CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA. OITIVA DOS CORRÉUS SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Esta Corte já sedimentou o entendimento de que a escolha de profissional da confiança do acusado é uma das formas de concretização do princípio da ampla defesa. II - Os autos dão conta de que o paciente, ao ser citado, afirmou possuir patrono constituído, porém não informou os dados necessários para que se procedesse à sua intimação. Assim, findo o prazo para a apresentação de resposta à acusação sem que houvesse manifestação da defesa, o juízo determinou a nomeação de defensor dativo para atuar em defesa do réu. III - A essa situação aplica-se o art. 565 do CPP, que dispõe: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". IV - Não há falar em nulidade decorrente da retirada do paciente da sala de audiências por ocasião da oitiva de corréus. Observância ao que dispõe o art. 191 do CPP. V - Não é de se acolher a alegação de nulidade decorrente da inobservância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo que teria advindo para o réu. VI - Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, pois "(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas" (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. VII - Ademais, a decisão ora questionada está em perfeita consonância

com o que decidido pela Primeira Turma desta Corte ao apreciar o HC 103.525/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. Esse entendimento foi corroborado pela Segunda Turma ao apreciar o RHC 110.623/DF, de minha relatoria. VIII – Ordem denegada. (HC 112212, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-2012 PUBLIC 03-10-2012)” “JUÍZO – PARCIALIDADE – DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE – NEUTRALIDADE. A parcialidade do Juízo há de ser demonstrada, sendo elemento neutro o fato de haver implementado decisões contrárias à parte. TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – PERGUNTAS – ORDEM. O disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal não obstaculiza a possibilidade de, antes da formalização das perguntas pelas partes, dirigir-se o juiz às testemunhas, fazendo indagações. SENTENÇA DE PRONÚNCIA – NATUREZA – TERMOS. A pronúncia faz-se mediante decisão interlocutória, cabendo ao Juízo fundamentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. (HC 105538, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27-04-2012 PUBLIC 30-04-2012)” Na mesma esteira de decisões o STJ e o TRF vêm mantendo a indagação por parte do magistrado. “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI Nº 11.690/08. INTERPRETAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008, alterou a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, passando-se a adotar o procedimento do Direito Norte-Americano, chamado cross-examination, no qual as testemunhas são questionadas diretamente pela parte que as arrolou, facultada à parte contrária, a seguir, sua inquirição (exame direto e cruzado), e ao juiz os esclarecimentos remanescentes e o poder de fiscalização. 2. A nova lei objetivou não somente simplificar a colheita de provas, mas procurou, principalmente, garantir mais neutralidade ao magistrado e conferir maiores responsabilidades aos sujeitos parciais do processo penal, que são, na realidade, os grandes interessados na produção da prova. 3. No caso, observa-se que o juiz de primeiro grau concedeu às partes a oportunidade de questionar as testemunhas diretamente. A ausência dessa fórmula gera nulidade absoluta do ato, pois se cuida e de regramento jurídico cogente e de interesse público. 4. Entretanto, ainda que se admita que a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquiridores de testemunhas, à luz de uma interpretação sistemática, a não observância dessa regra pode gerar, no máximo, nulidade de natureza relativa, por se tratar de simples inversão, dado que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar as suas perguntas, ainda que subsidiariamente, para o esclarecimento da verdade real, sendo certo que, aqui, o interesse protegido é exclusivo das partes. 5. Não se pode olvidar, ainda, o disposto no art. 566 do CPP: “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 6. Habeas corpus denegado.” (HC 121.215/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 22/02/2010)” “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 212 DO CPP. INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. A Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008, alterou a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, passando-se a adotar o procedimento do Direito Norte-Americano, chamado cross-examination, no qual as testemunhas são questionadas diretamente pela parte que as arrolou, facultada à parte contrária, a seguir, sua inquirição (exame direto e cruzado), e ao juiz os esclarecimentos remanescentes e o poder de fiscalização. 2. Entretanto, ainda que se admita que a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquiridores de testemunhas, à luz de uma interpretação sistemática, a não observância dessa regra pode gerar, no máximo, nulidade relativa, por se tratar de simples inversão, dado que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar as suas perguntas, ainda que subsidiariamente, para o esclarecimento da verdade real, sendo certo que, aqui, o interesse protegido é exclusivo das partes. 3. No caso, muito embora a oitiva das testemunhas não tenha sido procedido com perguntas feitas inicialmente pelas partes, não se observando,

portanto, a ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, certo é que, o ato cumpriu sua finalidade, como destacado pelo acórdão recorrido, com ampla participação das partes, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente garantidos, motivo pelo qual não verifico qualquer prejuízo efetivo ao acusado.4. Recurso a que se nega provimento.(RHC 27.719/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 13/10/2011)" "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 212 DO CPP. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO INEXISTENTE. FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.212CPP226CPPPreliminar de Nulidade. O art. 212 do CPP, em sua nova redação, apenas modificou a técnica de inquirição, podendo as partes indagar diretamente ao depoente. Apesar da reforma, o magistrado não está impedido de perguntar às testemunhas. Além disso, sabe-se que o descumprimento importa em nulidade relativa, a ser alegada na. 212CPP (70048706758 RS , Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, TRF, Data de Julgamento: 14/06/2012, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/06/2012)" "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ART. 316 DO CP. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 514 DO CPP. LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VISLUMBRADO. ORDEM DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DA CONCUSSÃO COMPROVADOS. CRIME DE QUADRILHA NÃO CONFIGURADO. PENA-BASE MANTIDA. SÚMULA 444 DO STJ. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO VERIFICADA. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA READEQUADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO APELOS DA DEFESA.1. A denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, descabendo falar-se em inépcia da exordial.2. A não observância do rito previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não caracteriza cerceamento de defesa, já que os autos foram instaurados com base em inquérito policial, a teor da Súmula 330 do STJ 3. Interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela autoridade judicial competente, em decisões fundamentadas, para angariar provas em investigação criminal no âmbito da "Operação Avalanche", realçando a existência de razoáveis indícios de autoria e participação dos acusados em crime apenado com reclusão, obedecendo aos preceitos constitucionais e aos ditames previstos na lei 9.296/96, sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência a admissibilidade de sucessivas prorrogações.4. Pedido de expedição de ofício à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo para prestar esclarecimentos acerca de suposta carta e CD contendo gravação ambiental não comportava deferimento, vez que há laudo referente à gravação efetuada.5. Não configurada a nulidade nos depoimentos testemunhais por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, pois permite-se a continuidade na ordem anterior anterior de inquirição de testemunhas, começando pelo magistrado e findando com as perguntas diretas das partes, como ocorrido nos autos.6.Materialidade delitiva, autoria de três réus e dolo na concussão amplamente comprovado através do conjunto probatório, notadamente por monitoramento telefônico, vigilância e escuta ambiental, todos autorizados judicialmente, depoimentos da testemunha do Juízo e da vítima e prova pericial realizada nos computadores dos réus.7. Manutenção da absolvição do corréu Eduardo por ausência de dolo, não sendo demonstrado que tinha conhecimento de que as informações que repassava seriam utilizadas para o cometimento de crime. 8. Mantém-se a absolvição pelo crime de quadrilha por ausência do número de agentes e de demonstração que a associação se destinava à prática de mais de um crime. 9. Acrescida a pena de dois dos réus por conta do reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal em 1/5 (um quinto), por coordenarem as atividades do grupo, dirigindo as atividades de AFONSO, orientando-o na coleta de informações sigilosas que seriam posteriormente utilizadas na prática do crime de concussão. 10. Inocorrência de continuidade delitiva, já que os dois crimes foram separados por intervalo de aproximadamente um ano e meio, inviabilizando a aplicação do art. 71 do CP.11. Observando os critérios

adotados para a fixação da pena corporal, a pena de multa foi readequada, de ofício, para 30 (trinta) dias-multa. 12. Rejeitadas as preliminares e negado provimento aos recursos da defesa, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial para fazer incidir a agravante do artigo 62, I do Código Penal aos réus FRANCISCO PELLICEL JUNIOR e EDISOM ALVES CRUZ, adequar a pena de multa ao patamar utilizado na fixação da pena privativa de liberdade e condenar o réu AFONSO JOSÉ PENTEADO AGUIAR como incurso no artigo 316, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de $\frac{1}{2}$ (meio) salário mínimo, sendo substituída por restritiva de direitos. (TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, ACR 0014315-17.2008.4.03.6181, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 28/08/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/09/2012)“ Também afasto a preliminar de nulidade pelo ingresso na residência pois apesar do réu engar a autorização, é fato que Bruna não se manifestou, e a mesma indicou aos policiais o local onde guardava o entorpecente. Mas não é só, a fundada suspeita estava presente, e a própria ré declinou local onde guardava drogas, autorizando o ingresso, onde a diligência foi frutífera, ou seja, a flagrância permitia o ingresso na residência, não existindo irregularidade da abordagem e da localização da droga e da munção na casa onde Bruna se encontrava, ainda que fosse de Benedito. Ademais, policiais experientes não ingressariam em local sem autorização por parte da investigada tanto que mencionaram que existiu a autorização, o que leva ao afastamento da preliminar No mérito, a materialidade está presente pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/08), boletim de ocorrência (fls.09/12), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), auto de constatação preliminar (fls.15/16), depósito judicial (fls.150), laudo pericial de munições (fls.157/159), laudo caderno de contabilidade (fls.163/170), laudo celulares (fls.209/218), laudo químico toxicológico (fls.219/223) além da prova oral coligida. Quanto a autoria, Benedito confessou as munições e que recebeu do primo mesmo ciente da irregularidade, e quando as drogas desconhecia os fatos, pois começou a namorar a Bruna, e iniciaram o relacionamento em sua casa no dia 01/10/2021, e no dia 04 foram presos. No dia estava no bar, e saiu apos se despedir e tinha visto a viatura e foi abordado. Desconhecia as drogas e que Bruna estava carregando a mesma ou que tenha ocultado algo em sua casa. O caderno era seu e as anotações eram do trabalho do sitio. Ficou em seu carro com os policiais e Bruna ficou com a outra viatura e foram primeiro, e eles se comunicavam por telefone, e perguntavam para sua pessoa. Bruna preferiu ficar em silêncio Matheus disse que foram apurar perturbação de sossego em um bar que já era conhecido por problemas inclusive de trafico, e ao chegarem perceberam um casal sair rapidamente e ingressaram em um veiculo, saíram atrás e fizeram a abordagem, sendo que Benedito era o motorista e nada foi encontrado consigo. Bruna estava de passageira e no local onde estava, foi encontrado na porta 04 frascos de lança perfume, sendo que ela admitiu ser de sua pessoa, e continuando a perguntar, ela entregou diversas capsulas de cocaína e novamente indagada a respeito de algo no carro, ela disse que na residência onde estava com Benedito havia mais drogas. Ela levou a equipe apos o pedido de apoio ate o sitio, sendo que acompanhou a busca, tendo autorizado o ingresso na casa, mas não lembrava onde estava a droga, ate que fizeram contato com o Benedito que estava em outra viatura, e ele disse que estava embaixo da pia, e de fato encontraram um tijolo de maconha cortado, e a ré admitiu o fracionamento para venda. Durante a procura, encontraram munições de 45 no guarda roupa sendo que Bruna disse que pertencia a Benedito e também localizaram um caderno de contabilidade, que Bruna teria assumido que seria sua. Existiam denuncias de tráfico no local por um casal, apos a separação de Bruna, e já a conhecia mas nunca a abordou. Conhecia Bruna da própria cidade e não conhecia Benedito. Eles autorizaram a entrada na residência. Conhece o irmão de Bruna, pois ele é frentista do posto onde as viaturas são abastecidas. Foram apreendidos celulares dos réus, sendo a grande maioria pertencentes a Bruna. Eduardo reiterou a manifestação de Matheus acrescentando que Benedito era o caseiro do local, e que estava preocupado com os cuidados do local. Tatiana apenas atestou os bons antecedentes de Bruna Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e

demonstrada. Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a tes-temunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401) "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. - Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes". (STJ, 5.a Turma, HC 115516/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, v.u., j . 03.02.2.009; pub. DJe de 09.03.2.009) "STJ - HABEAS CORPUS TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA MORMENTE QUANDO CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONTESTAÇÃO DO EXAME PERICIAL QUE AFASTOU A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ACUSADO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. (...) 2. De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. (...)". (Gritos nossos) (HC 98766/SP HABEAS CORPUS N. 2008/0009791-4 -Rel. Min. Og Fernandes - 6a Turma. DJe. 23/11/2009). Alias, tratou-se de abordagem de rotina, que restou frutífera com localização de drogas, e dinheiro, além de celulares. Ademais, foi encontrado com Bruna drogas em grande quantidade além de mais um pedaço de maconha na casa de Benedito, sendo que a quantidade de drogas apreendida demonstra que não seria apenas uma usuária, mas sim vendedora de drogas. Tanto que

os policiais disseram que já existiam denúncias envolvendo Bruna com a venda de drogas, e acabou abordada com grande quantidade de entorpecentes, além de dinheiro sem origem. Ainda, Bruna disse que não tinha labor, e não teria meios de sustentar a grande quantidade de drogas existente consigo, o que reforça a prova de acusação de venda de drogas. A evidente intenção de mercancia surge do comportamento da ré, das circunstâncias do ocorrido e da própria condição de acondicionamento da droga, ou seja, dividida em pequenas porções, conforme apurado, hábeis à venda imediata, como é comum em casos de tráfico de entorpecentes, além de pedaço de maconha cortado e que seria fracionado para venda. Em suma, a prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, evidenciam a realidade do tráfico exercida pela ré. Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). A lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos carreados, como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração, etc. Nesse sentido: "A inversão do ônus da prova, uma vez que o trabalho acusatório demonstrou suficientes indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, às defesas indicarem fatos que afastasse, inequivocamente, os seguros indicativos da participação das acusadas no crime. "Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessária prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos que cercam o agente infrator podem fornecer o material de convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito, elementos indiciários, como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota de comércio ilícito etc. Erigir-se, como regra, a necessidade de prova direta da finalidade comercial da substância entorpecente em poder do acusado, para fazer incidir o art. 12, por um lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto de vista jurídico constituir-se numa teratologia." (RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001.p. 157). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO-DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel A. Duarte - Julgamento: 8/3/2010) . Apelação - Tráfico DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - Interceptação Telefônica PROVIMENTO PARCIAL. Mantém-se a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes quando devidamente caracterizadas a autoria, a materialidade e tipicidade. [...]. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza múltipla, caracterizando-se quando o agente pratica um ou mais dos núcleos do tipo previsto no art.33 da Lei 11.343/06. (AC nº 1.0384.07.053086-8/001 - Rei. WALTER PINTO DA ROCHA - Data da Publicação: 04/04/2008). Não se olvide que o

fato de ser usuário não impede a traficância, ate porque, é relativamente comum a participação do dependente no preparo como forma de receber a droga pelo trabalho, como se apresenta neste caso, já que nenhuma quantia em dinheiro foi apreendida. Ademais, é comum que usuário de drogas passem a fazer a mercancia como forma de sustentar a dependência. "Releva notar que a prova do fato criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não nega ("Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare"). Ainda: "Muito embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa constitucional" (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rei. José Habice). (TJSP, Apelação Criminal nº 993.05.001105- 4, São Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rei. CARLOS PIASOTTI, j .25.6.2009) No entanto, em relação a Benedito a prova permaneceu frágil, já que ate mesmo os policiais não conseguiram demonstrar o envolvimento dele com o tráfico, embora plausível e possível, não ha a certeza da autoria e nesse caso a dúvida beneficia o réu. No tocante ao delito de associação para o tráfico não se comprovou a estabilidade entre os réus. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PERMANENTE - 'ANIMUS' ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO - PROVAS INSUFICIENTES - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - AUMENTO DAS PENAS-BASE - PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E DA QUALIDADE DA SUBSTÂNCIA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART 33, § 4.º, DA LEI 11.343 - IN APLICABILIDADE - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 'Para a configuração do crime autônomo de associação para o tráfico - art. 35 da LEI 11.343/06 - não é suficiente a convergência de vontades para a prática das infrações dos artigos 33 e 34 da referida LEI. E indispensável a prova do 'animus' associativo, ou seja, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado'. 'A fixação das penas-base pelo crime de tráfico de entorpecentes deve obedecer preponderantemente à natureza e quantidade da substância entorpecente em relação às circunstâncias judiciais, conforme determina o art. 42 da LEI 11.343/06'. 'A causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da LEI n.º 11.343/06, só é aplicável aos condenados pelo delito de tráfico de entorpecentes que não integrem organização criminosa e não se dediquem com habitual idade a este tipo de atividade'. (TJMG, 1." CCrim., Ap. 1.0145.07.425302-5/001, Rei. Des. Eduardo Brum, v.u.J. 16.09.2008; pub. DO MG de 26.09.2008.) EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO (ART. 35 DA LEI N 11.343/06 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO VENCIDO DO RE VISOR - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - PRETENSÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n.11.343/06, deve ser comprovado em provas que indiquem, deforma incontroversa, que os envolvidos sejam efetivamente integrantes de um grupo coeso e permanente, para o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes. (Embargos infringentes em apelação criminal - Processo nº 2008.015677-2- julgamento em 03/12/2008-Órgão Julgador- Seção Criminal-Relator- Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel A. Duarte). Não existiu qualquer prova de que os acusados realmente constituíram uma associação para a prática do tráfico, pelo contrario, sequer é possível apontar que Benedito estivesse envolvido na venda de drogas. No entanto, mais do que comprovado o envolvimento de Benedito no caso das munições, as quais tinham potencial lesivo como constatou o laudo, não existindo qualquer documento regularizando o objeto, ou autorizando sua posse, de modo, que resta evidente o delito praticado. A prova não é ilícita, tampouco necessitava de mandado, já que estava em flagrante delito, pois possuía munições sem qualquer autorização ou permissão. "A CIRCUNSTÂNCIA DE ARMA DE FOGO ESTAR DESMUNIDA NÃO EXCLUI, POR SI, A TIPICIDADE DO DELITO PORQUE OFERECE POTENCIAL PODER

DE LESÃO. BASTA O SEU TRANSPORTE FORA DE CASA, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE. A MATERIALIDADE ESTÁ COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME DE ARMA DE FOGO, CONCLUDENTE DE POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADA EFICAZMENTE PARA PRÁTICA DO CRIME. O QUADRO PROBATÓRIO NÃO DEIXA DÚVIDAS A RESPEITO DA AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DOS RÉUS APELADOS. PROVA TESTEMUNHA SEGURA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDO. (AP. 2006.050.00140, 8º C., REL. MARIA RAIMUNDA T. DE AZEVEDO, 09.02.2006. V. U).” Desta forma, a procedência parcial da ação é de rigor condenando Bruna pelo tráfico e Benedito pela posse das munições aptas. Passo a dosimetria da pena. 1) BENEDITO DIRCEU DE SOUZA. Atento ao disposto no artigo 59 do CP, o réu tem maus antecedentes, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência que resta compensada com a atenuante da confissão. Ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena. A reprimenda permanece em 01 ano e 02 meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, e o regime semi aberto para início de cumprimento de pena já que é portador de maus antecedentes e reincidente. No entanto, considerando o tempo de prisão, já faria jus a progressão, de modo, que considero e fixo o regime aberto. 2) BRUNA VITORIA FRANHANI DE JESUS. Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, verifico que a quantidade de droga era significativa, e renderia lucro considerável, e com grande valor econômico o que mostra a desvalia da conduta, sendo que este fator, pode ser usado na fixação da pena base. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada” (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). “A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (STF - RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.). Assim, reconhecendo este fator, a apontar a culpabilidade acima da média, o que leva a fixação da pena em 1/5 acima do mínimo. Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento de pena. Possível a aplicação do redutor, em que pese não ter comprovado labor lícito, não há prova de que estivesse envolvida em organização criminosa, de modo, que reduz a pena em 2/3, totalizando 02 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa. Fixo a míngua de outro elemento o dia-multa no mínimo legal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para a ré, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de tráfico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminosa, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Saliento que não seria possível a aplicação da substituição tendo em vista a vedação do

inciso III do artigo 44 do Código Penal, já que possui circunstância judicial negativa. Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões. "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)” (STJ, Resp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016) Levando-se em consideração a quantidade de drogas, e o alcance significativo de usuários, a indicar uma maior reprovabilidade da conduta, somado as circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas, e pontuado-se o bem jurídico protegido, além da pena aplicada, fixo o regime semi aberto para início de cumprimento de pena, o entanto, considerando o tempo em que permaneceu presa também faria jus a modificação do regime, de modo que fixo o regime aberto. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 33 da lei 11343/06 a ré BRUNA VITORIA FRANHANI DE JESUS a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto (já considerado o tempo de prisão como progressão do semi aberto para aberto), além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa e o réu BENEDITO DIRCEU DE SOUZA como incurso no artigo 12 da lei 10826/03 a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime aberto (já considerado o tempo de prisão como detração do semi aberto para o aberto), além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. Para ambos o valor do dia multa consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Ainda absolvo os reus das demais imputações contidas na denúncia no tocante ao delito de associação e também para Benedito o crime de trafico, todos com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Custas pelos acusados nos termos da lei. Diante do regime e a detração possível a substituição da prisão pelas seguintes cautelares em relação a Benedito: Comparecimento mensal em juízo; proibição de frequência a bares, danceterias, locais mal afamados, biqueira; recolhimento domiciliar diário a partir das 19:00 e integral aos finais de semana e feriados com exceção de trabalho, estudo ou frequência a culto religioso. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Benedito. Ficam mantidas as cautelares já fixadas em relação a Bruna. Autorizo assegurada a contraprova e desde que não providenciado, a incineração da droga apreendida independente do trânsito em julgado. Ainda, declaro o perdimento do valor em dinheiro, e dos celulares de Bruna já que não comprovada a aquisição lícita. No tocante ao veículo e celulares de Benedito devesse comprovar a aquisição lícita dos aparelhos e a documentação do veículo para a liberação. Autorizo ainda a destruição das munições apreendidas. Oportunamente, após o trânsito, lancem os nomes dos réus no Rol dos Culpados e providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Pelas partes e pelos réus foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

Parte 1:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjssp_jus_br/EaogjoCo_NBFvLgMbrW6FWYBGP9d2hwmf9-urH6CMLfIWg?e=fqboHm

Parte 2:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/ESwVrAzqSWxJqPgry76hZV8BpF2hnmX0gnClwFJUyRE5tw?e=ES8qyq

MM. Juiz: assinado digitalmente